

1501302-92.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Juízo, o acusado admitiu a prática do tráfico de drogas. Disse que toda a droga e objetos apreendidos lhe pertenciam. Informou que havia sido preso por tráfico e deixou a prisão dois meses antes da data dos fatos ora apurados. Possuía uma dívida com um traficante em razão da droga que perdeu quando foi preso naquela ocasião. No dia dos fatos foi contratado por uma pessoa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501302-92.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501302-92.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FAGNER NAGY FERNANDES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

V I S T O S.

FAGNER NAGY FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 16:52 horas, na Rua Judith Marchareth, 959, Bairro Rosele, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 256,68 gramas de maconha (distribuídos em 2 porções), substância esta capaz de causar dependência. O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar a fls. 117/122. A denúncia foi recebida a fls. 128/130. No decorrer da instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes e, após, interrogado o acusado (fls. 161/164). Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais (fls. 159/160), oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação, ao passo que a Defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e da causa de diminuição de

pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a imposição de regime inicial diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudos de constatação provisória de fls. 33/34 e exame químico toxicológico encartado a fls. 83/85, que resultaram positivos para maconha.

E a responsabilidade criminal do acusado é indubitosa.

Com efeito, interrogado em Juízo, o acusado admitiu a prática do tráfico de drogas. Disse que toda a droga e objetos apreendidos lhe pertenciam. Informou que havia sido preso por tráfico e deixou a prisão dois meses antes da data dos fatos ora apurados. Possuía uma dívida com um traficante em razão da droga que perdeu quando foi preso naquela ocasião. No dia dos fatos foi contratado por uma pessoa para levar um tijolo de maconha e uma balança de precisão para outra pessoa que o esperava no ferro velho, onde foi abordado pelos policiais. Receberia R\$ 150,00 pelo serviço e usaria tal valor para pagar sua dívida. Prefere não dizer o nome da pessoa que o contratou. A porção pequena de maconha era para seu consumo. Não conhecia os policiais.

E as demais provas produzidas nos autos demonstram que toda a droga apreendida pertencia ao acusado, que se dedica ao tráfico de drogas.

De fato, ouvido em Juízo, o Policial Militar Álvaro disse que no dia dos fatos estava em patrulhamento e viu o acusado trafegando normalmente com uma bicicleta. Percebeu que ao avistar a viatura, o acusado aumentou a velocidade e ingressou em um ferro velho. Viu que ele estava com um saquinho branco na mão. O acusado abandonou a bicicleta e se escondeu atrás de um fogão velho. Pediram que ele saísse do local. O réu caminhou em sua direção e foi abordado. Em poder dele localizou uma pequena porção de maconha, um celular, R\$ 40,00 em dinheiro e uma balança de precisão. Foi atrás do fogão, onde o acusado havia se escondido, e encontrou uma sacola branca no chão, contendo em seu interior meio tijolo de maconha. O réu alegou que o tijolo de maconha não lhe pertencia. Não havia mais ninguém no ferro velho além do réu. Não o conhecia.

E o destino do entorpecente apreendido em poder do réu é manifesto, vez que trazia consigo uma grande quantidade de maconha (256,68 gramas). A quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida (uma porção individualmente embalada, pronta para imediata comercialização, e outra maior, para ser desfragmentada em porções menores para venda) já seriam suficientes, por si sós, para demonstrar a finalidade do tráfico de entorpecentes. Mas não é só. Como já visto, também foi apreendida em poder do acusado a quantia de R\$ 40,00 em dinheiro sem comprovação de origem lícita, ou seja, o produto do crime, além de uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado para a prática do tráfico. Assim, não prevalece a versão do réu de que teria sido simplesmente contratado para o transporte da droga, como quis fazer crer em juízo, mesmo porque além de não haver prova alguma de tal fato, ônus que era dele, o policial afirmou em juízo que não havia mais ninguém no ferro velho, afastando, portanto, a tese de que teria alguém esperando pelo acusado no local para receber o entorpecente.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a finalidade de tráfico de entorpecentes é evidente.

Verifica-se, portanto, que a prova acusatória forma um todo coeso e concorde, perfazendo a necessária certeza para a prolação do decreto condenatório, afastando-se toda e qualquer tese absolutória.

Assim, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, em face da sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

O réu possui antecedentes criminais, tendo sido condenado por tráfico de drogas (condenação certificada a fls. 37/38, cuja sentença já transitou em julgado para a Defesa, conforme consulta por mim realizada ao respectivo processo). Analisando, ainda, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo

42 da Lei nº 11.343/06, notadamente a grande quantidade de droga apreendida (256,68 gramas de maconha), fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a atenuante da confissão espontânea, reduz a pena base ao patamar mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria penal, entendo que o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Isso porque o réu trazia consigo uma grande quantidade de maconha e, menos de dois meses após deixar o cárcere, por força de ter sido concedido a ele o direito de recorrer liberdade na sentença que o condenou por tráfico (condenação esta já transitada em julgado para a Defesa, como já visto), logo voltou a delinquir, praticando o crime objeto desta ação penal. Diante de tais circunstâncias e considerando que o acusado não possui emprego lícito comprovado nos autos, resta claro que ele não se trata de um traficante eventual, que circunstancialmente resolveu vender determinada quantidade de droga para sustentar o vício, mas sim que desenvolve uma atividade criminosa habitual, fazendo do tráfico seu meio de vida e fonte de renda. Assim, não preenche o réu os requisitos necessários à concessão do benefício ---"desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa---. Neste sentido: "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. SITUAÇÃO IDÔNEA A SER VALORADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE DROGA. USO NA PRIMEIRA FASE E NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack. IV - De mais a mais, o Tribunal de origem afirmou que o paciente "assume funções de chefia e direção em organização criminosa. Acrescente-se que, conforme documento de fl. 52, o réu apresenta inúmeras passagens pela Vara da Infância, fazendo do crime o seu meio de vida desde a adolescência" Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes" (AgRg no HC n. 588.716/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/08/2020). V - Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. VI - Ainda, insta consignar que é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Nesse sentido: AgRg no REsp n.

1.255.180/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/02/2013; HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017; AgRg no REsp n. 1.779.825/RO, Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/05/2019. VII - Regime inicial. A quantidade e a natureza do entorpecente - 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack - foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 641.285/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). "TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos guardas civis municipais em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada - Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (16 porções de 'maconha', com peso líquido de 18,11 gramas), além de dinheiro e celular - Crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e envolvendo adolescentes - Condenação eskorreita. PENAS E REGIMES PRISIONAIS - Bases nos mínimos. Natureza e quantidade de droga que, embora relevante, não justificam a exasperação - Menoridade relativa e agravante do artigo 61, II, "j", do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Compensação - Exclusão do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Réu que ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, três delas por ato infracional equiparado ao tráfico. Causas de aumento do artigo 40, III e VI, da Lei de Drogas. Acréscimo de 1/5 - Regime inicial fechado - Apelo ministerial provido para afastar a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, majorar as penas e fixar o regime inicial fechado. (TJSP; Apelação Criminal nº 1501321-34.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Des. Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Data de Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021). "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEFESA PLEITEIA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E A MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA QUE SEJA ELEVADA A PENA-BASE, AFASTADA A INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006, FIXADO O REGIME FECHADO E CASSADA A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS - COM INTEIRA RAZÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO - PENAS ALTERADAS - RÉU PRIMÁRIO, MAS COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DEDICAÇÃO AO NEFASTO COMÉRCIO DEMONSTRADA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA - IMPOSSIBILIDADE DE PERMUTA E DE RIGOR O REGIME FECHADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE EMPREITADA CRIMINOSA - A MULTA NÃO PODE SER REDUZIDA, POIS JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL - EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal nº 1500927-84.2019.8.26.0628; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Des. Relator: Euvaldo Chaib; Data de Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020).

O valor do dia-multa, diante da situação econômica desfavorável do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra FAGNER NAGY FERNANDES, qualificado nos autos, e o condeno ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O regime para o cumprimento de pena é o inicial fechado, único recomendável diante da latente e concreta gravidade do crime (o réu possui antecedentes criminais pela prática de tráfico e se dedica ao comércio espúrio, de forma que não se enquadra o delito em questão na figura do chamado "tráfico privilegiado", como já visto), fomentador de tantas outras práticas ilícitas, restando evidentemente prejudicada a aplicação da Lei nº 9.714/98, mesmo porque os objetivos do legislador com a promulgação desta Lei demonstram que ela afeta apenas aos crimes menos graves, distanciam-se em muito da hedionda mercancia.

Demais disso, ainda que alguns requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem

favoráveis aos réus (o que não é o caso, vez que a pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão), não estaria configurado o previsto pelo inciso III, in fine, do mencionado dispositivo legal, ou seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". O traficante é um grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país. A insuficiência da substituição em tela para a repressão e prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto é patente, por conseguinte.

Considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime de pena imposto, e mormente o fato de ter sido preso em flagrante delito e encontrando-se detido até hoje, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu, apesar de primário e de bons antecedentes, respondeu a ação penal, quando havia apenas o "fumus boni iuris", preso, após a prolação de sentença, surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade" (RJDTCRIM 13/181). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Logo, o réu não poderá recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra, mesmo porque continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como já exposto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e nas que a mantiveram.

Ressalto que eventual detração penal (art. 387, § 2º do CPP) deve ser postulada, oportunamente, ao juízo das execuções criminais competente, o qual possui condições de aferir a presença dos requisitos legais, especialmente os de natureza subjetiva. Neste sentido: "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, nocividade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500272-11.2021.8.26.0542; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

Por fim, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, declaro perdidos em favor da União o celular, a balança e os valores descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, pois se tratam de instrumentos utilizados para a prática do crime de tráfico de entorpecentes e produto dele.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da Lei.

P. I.C.

Araçatuba, 17 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA